Processo nº 0060700-36.2022.8.17.2001

AUTOR: FERNANDA MARIA DA SILVA CRUZ VIEIRA

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

SENTENÇA COM FORÇA DE MANDADO

Vistos, etc.

FERNANDA MARIA DA SILVA CRUZ VIEIRA, através de advogado devidamente constituído (id. 108509983) propõe a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MORAIS com PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face da **SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A**, objetivando tratamento com a substância BENLYSTA ® 400mg (BELIMUMABE) aplicação endovenosa, conforme prescrições da reumatologista Cláudia Diniz Lopes Marques, CRM 10979, RQE 7393 – 6 frascos no primeiro mês com manutenção de 2 frascos a cada 28 dias (id. 107304974) – para fins de tratar Lupus Erimatoso Sistêmico (CID 10: M32.1).

Consta na exordial que a seguradora demandada negou o fornecimento da medicação sob o fundamento de que a solicitação não atende aos critérios do item 65, da Diretriz de Utilização (DUT) estabelecida pela Agência Nacional de Saúde – ANS (ids. 107165284, 107165285 e 107165286).

Dado ao narrado, propõe a presente demanda, pugnando pela tutela provisória para compelir a ré a imediatamente autorizar, custear e garantir a medicação vindicada, nos moldes prescritos pela médica assistente (id. 107304974).

No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e a condenação da demandada a pagar indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 50.000,00, e eventuais danos materiais que venham a ser suportados pela autora, caso venha a arcar com o início do tratamento.

Dá a causa o valor de R$ 107.470,94, o qual assevera ter atribuído considerando o valor anual do tratamento (art. 292, §2º, do CPC/2015), observando o preço do fármaco apontado da tabela CMED (id. 107165289). Pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita, juntando declaração de hipossuficiência (id. 107162628) e Demonstrativo de Pagamento (id. 107165282).

Despacho inaugural determina a intimação das partes para: **1)** autora: juntar procuração, quantificar os danos morais pretendidos, e comprovar situação econômica condizente com a justiça gratuita requerida; e **2)** ré para falar sobre o pedido de tutela,

bem como cita para comparecer à audiência do art. 334, do CPC (id. 107358314).

A autora, em emenda à inicial (id. 108509982): colaciona procuração do advogado peticionante (id. 108509983); quantifica os danos morais no importe de R$ 50.000,00, pleiteando a retificação do valor da causa para R$ 110.264,00; e reitera o pedido pela gratuidade judiciária, ao argumento de que é a única financiadora da subsistência de sua unidade familiar (marido e filho), juntando Declaração de IRPF e declaração de isenção de imposto de renda de seu esposo (ids. 108509988 a 108509990).

A ré colaciona manifestação sobre a tutela (id. 112706899) e oferta contestação (id. 113285741). Sem alegar preliminares, a Sul América, inicialmente, requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome de Thiago Pessoa Rocha, OAB/PE 29.650 (procuração e substabelecimento nos ids. 113285774 e 113285779).

No mérito, defende a legalidade da negativa, ao argumento de que: **1)** há exclusão contratual para cobertura de medicamentos ministrados em ambiente domiciliar (item 16 e 16.10, das Condições Gerais da Apólice – id. 113285759, págs. 19/20); **2)** a solicitação não atende aos critérios do item 65, da Diretriz de Utilização (DUT) do Rol da ANS (Anexo II, da RN 465/2021); **3)** o Rol da ANS é taxativo, conforme julgados do STJ (EREsp 1886929 e EREsp 1889704); **4)** inexistem os danos morais pleiteados; e **5)** não há comprovação dos danos materiais alegados.

A autora, deixa de apresentar réplica, apesar de ter sido devidamente intimada para tal desiderato (certidão de id. 118374325).

Instadas a informar se há novas provas a produzir, a parte ré manifesta desinteresse na produção de provas novas (id. 118911372), quedando-se silente a parte autora (certidão de id. 122488473).

É o que importa relatar.

Vieram os autos conclusos.

À partida, considerando os documentos juntados aos autos, **DEFIRO** o benefício da gratuidade judiciária. Ciente a autora quanto ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.

Outrossim, **DEFIRO** o pedido formulado pela ré nos ids. 112706899 e 113285741, para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de Thiago Pessoa Rocha, OAB/PE 29.650, procedendo a Diretoria Cível do 1º Grau com as devidas anotações

O feito se apresenta suficientemente instruído e comporta julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, inciso I, do CPC/2015, por não haver necessidade de dilação probatória. Registre-se que, intimadas a informarem interesse em produzir provas, a ré expressou desinteresse (id.112517832) e a autora ficou silente (id. 117212504).

Os contratos de seguro, por definição legal, encerram relação de consumo, portanto devem ser interpretados sob ótica da legislação que lhe é própria, ainda que definidos ou regulamentados em textos outros.

Tal entendimento foi ratificado pelo STJ através do enunciado da Súmula 608: "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*" (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

Nas relações de consumo, notadamente aquelas que se firmam mediante simples adesão de uma parte ao contrato previamente estabelecido pela outra, devem preponderar, sobre a letra fria do texto, a boa-fé dos contratantes e o equilíbrio contratual.

Importa ressaltar que a finalidade precípua do contrato de assistência médica entabulado com a ré é a manutenção da saúde dos contratantes.

Consta dos documentos juntados pela autora prescrições da reumatologista Cláudia Diniz Lopes Marques, CRM 10979, RQE 7393, apontando a grave enfermidade que acomete a autora – Lúpus Eritomatoso Sistêmic o (LES), CID 10 M32.1 – e a necessidade do tratamento com o fármaco BENLYSTA 400mg (BELIMUMABE), em sua apresentação endovenosa (ids. 107304973 e 107304974).

Por outro lado, a negativa de cobertura perpetrada pela ré restou incontroversa nos autos (art. 374, inciso II, do CPC), posto que apresentada na manifestação prévia (id. 112706899) e na contestação (id. 113285741). Em síntese, aos argumentos de que não há cobertura contratual para medicamento de uso domiciliar (item 16 e 16.10, das Condições Gerais da Apólice – id. 113285759, págs. 19/20); e que a solicitação não atende aos critérios da DUT 65, do Rol da ANS.

De proêmio, impõe ressaltar que segundo jurisprudência pacífica do STJ, "*os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados*" (AgInt no AREsp 1678991/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Ressalte-se ainda que **cabe ao médico a decisão acerca do procedimento a que deverá se submeter o seu paciente**, incluindo, no presente caso os fármacos utilizados no tratamento. Neste sentido, segue recente julgado do Tribunal de Justiça de Pernambuco:

> EMENTA:**APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE– "ESTENOSE AÓRTICA" – "CATETERISMO CARDÍACO COM AORTOGRAFIA, IMPLANTE DE MARCAPASSO PROVISÓRIO TRANSVENOSO E IMPLANTE TRANSCATETER DE VALVA AÓRTICA (TAVI)"-NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA - ROL DA ANS QUE POSSUI SOMENTE AS COBERTURAS MINÍMAS -BOA-FÉ OBJETIVA – CONTRATO QUE POSSUI COBERTURA PARA DOENÇA - NEGATIVA DE TRATAMENTO - ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ -MÉDICO ASSISTENTE QUE POSSUI LEGITIMIDADE PARA INDICAR O TRATAMENTO ADEQUADO** - AFRONTA AO DIREITO À SAÚDE E AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DANO MORAL CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – SEGURADO IDOSO INTERNADO EM LEITO DE UTI – DOENÇA DIAGNOSTICADA COMO DE ALTÍSSIMO RISCO DE MORTE EM CURTO PRAZO - VALOR MANTIDO (R$ 5.000,00) – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA – EVIDENCIADO – DEMORA DE 21 DIAS – MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM R$ 1.000,00/DIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CASO DOS AUTOS QUE ENVOLVE OS DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE E À VIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - RECURSO IMPROVIDO. 1.**O rol da ANS não é taxativo, pois contém apenas a referência para a cobertura assistencial mínima obrigatória nos planos de saúde contratados no território nacional, de maneira que funciona como mero orientador das prestadoras de serviços de saúde. 2. Somente é admitida a intervenção da ANS em favor do consumidor, seja para afastar cláusulas**

abusivas ou ampliar a proteção contratual. 3.Segundo jurisprudência pacífica do STJ, mesmo na hipótese de entidades de autogestão, é permitido ao plano de saúde estabelecer quais as patologias contratualmente cobertas, mas não pode determinar a forma de tratamento a ser empregada, impedindo a utilização de exames, tratamentos ou medicamentos mais modernos e eficazes à melhoria do estado de saúde da segurada. 4. **Cabe ao médico responsável pelo caso, determinar o tratamento apropriado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade do paciente, desta forma, o plano de saúde não está habilitado, tampouco autorizado, a restringir as alternativas cabíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a vida do enfermo.** 5.No caso de negativa indevida de cobertura de tratamento médico, há clara afronta ao direito à saúde, além de inobservância ao princípio da dignidade da pessoa humana, não sendo o caso de mero aborrecimento. Por conseguinte, restam evidenciados os danos morais, sendo cabível a respectiva indenização. (...) (TJPE – APELAÇÃO CÍVEL 0026321-16.2015.8.17.2001, Rel. AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, julgado em **27/01/2020**, DJe)

Outrossim, não se mostra razoável a negativa efetuada pela seguradora com base em Diretriz de Utilização do Rol da ANS (RN 465/2021), principalmente por ser o fármaco necessário para tratar doença listada na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionados com a Saúde, da OMS: Lupus Erimatoso Sistêmico (CID 10: M32.1).

Além disso, não se pode desconsiderar que a diretriz de utilização é, como o próprio nome diz, uma diretriz, de sorte que o procedimento, de cobertura obrigatória, pode ser prescrito pelo médico assistente para situações diversas das ali elencadas, mediante a devida fundamentação.

A jurisprudência pátria já apresentou entendimento de que as diretrizes da ANS servem de mero parâmetro para os contratos regidos pela Lei 9.656/98, **não se sobrepondo à prescrição e orientação do médico assistente**. Neste sentido, seguem recentes julgados do Tribunais de Justiça de Minas Gerais/TJMG e do Estado de São Paulo/TJSP:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - COBERTURA DE TRATAMENTO - FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT - MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE - ROL DA ANS - EXEMPLIFICATIVO - NEGATIVA DE COBERTURA - IMPOSSIBILIDADE. - **Como já pacificado em nossa jurisprudência, as exigências da ANS são apenas diretrizes que não devem sobrepor às orientações médicas quanto ao procedimento indicado pela equipe médica que acompanha o paciente e que tem melhor condição de dizer sobre o seu real estado de saúde - A negativa de cobertura da ré, com amparo na exclusão de cobertura contratual, mostra-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja, o direito à vida e à dignidade humana**. (TJ-MG - AC: 10000170348213003 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 17/03/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: **22/03/2021**)

TUTELA ANTECIPADA – **Ação de obrigação de fazer – Cobertura para tratamento** de retocolite ulcerativa com o medicamento 'adalimumabe' – **Existência de prescrição médica** – Entidade de autogestão – Não incidência da legislação consumerista – Cobertura não prevista no rol da ANS – Irrelevância – Contrato que deve ser interpretado à luz da boa-fé contratual (art. 422 CC) e da função social do contrato (art. 421 do CC)- Aplicabilidade ao caso da súmula 102 deste do TJSP – Negativa abusiva – **Diretrizes de utilização (DUT) previstas no rol de procedimentos da ANS que não se sobrepõem à prescrição médica – Rol da ANS que é meramente exemplificativo** – Decisão interlocutória mantida – Recurso não provido (TJ-SP - AI: 21582950920208260000 SP 2158295-09.2020.8.26.0000, Relator: Rui Cascaldi, Data de Julgamento: 26/08/2020, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: **26/08/2020**)

Para além disso, considerando que a negativa se deu com esteio em diretriz de utilização do Rol da ANS, sobre este cumpre destacar que recentemente foi sancionada a **Lei nº 14.454/2022**, a qual estabelece critérios que determinam a cobertura de exames ou tratamentos não incluídos no rol de procedimentos do sistema de saúde suplementar, desde que preenchido algum dos critérios estabelecidos no parágrafo 13, do art. 10, da Lei 9.656/98, inserido pela Lei 14.454/2022, *in verbis*:

§ 13. **Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que**: (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14454.htm#art2)

I - **exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico**; **ou** (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14454.htm#art2)

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14454.htm#art2)

Pois bem, se o preenchimento de apenas um dos critérios supra indicados excepciona a taxatividade do Rol de Procedimentos da ANS, conduta diversa não poderia ser imposta às suas diretrizes. Sendo assim, ainda que a hipótese fática não se subsuma aos termos exatos da DUT, em sendo atendido algum dos requisitos do art. 10, §13, da Lei 9.656/98, deve-se autorizar o procedimento, repise-se, já previsto no Rol da ANS.

Dito isto, da solicitação médica de id.107304973, infere-se que há **eficácia comprovada, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico**, para o uso da medicação Benlysta (Belimumabe) para tratamento de Lupus Erimatoso Sistêmico (LES), *in verbis*:

"*Benlysta (Belimumabe) foi aprovado no Brasil em novembro de 2013 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Está indicado como terapia adjuvante em pacientes adultos com LES ativo, que apresenta atividade da doença e que esteja m em uso de tratamento padrão, incluindo anti-inflamatórios não esteroidais, corticosteroides, antimalárico ou outros imunossupressores.*

(…)

Recentemente o National Institute for Health and Care Excellence (NICE) recomendou a incorporação de belimumabe no sistema nacional de saúde do Reino Unido para os pacientes com LES em alta atividade (identificados na potnuação no SELENA-SLEDAI>10 e evidência sorológica de atividade da doença), permitindo acesso gratuito de um tratamento inovador aos pacientes. Em seu documento oficial de recomendação, o NICE ressaltou a importância de um tratamento inovador para o LES, visto que esta é ia condição clínica que limita significativamente a vida dos pacientes, principalmente mulheres, incapacitando-as de trabalhar e ter filhos. Além disso, destacou-se também a oportunidade identificada de redução dos efeitos colaterais provocados pelas terapias até então disponíveis, principalmente em função da redução da necessidade do uso de corticóides.

Bellimumabe é recomendado em vários protocolos internacionais e internacionais, como: Recomendação da Liga Europeia de Reumatologia (EULAR 2019) e também no Conselho Britânico tendo nível de evidência A. Conforme Technology appraisal guidanc do Instituto Nacional para Saúde e Cidados de Excelência do Reino Unido, a medicação deve ser utilizada se o escore da doença SELENA -SLEDAI for maior do que 10 (alta atividade da doença)."

Por fim, quanto à negativa ao tratamento medicamentoso, sob o fundamento de que há exclusão contratual para a cobertura medicamento ministrado em domicílio, citando os itens 16 e 16.10, das Condições Gerais da Apólice (id. 113285759, págs. 19/20), esta também não merece prosperar, por força da incidência da legislação consumerista, em especial o art. 47, do CDC.

As cláusulas limitativas ou obstativas das obrigações assumidas pelas seguradoras, notadamente aquelas às quais os consumidores aderem por força da própria natureza adesiva do contrato, devem ser interpretadas à luz dos princípios da boa-fé e da equidade, e na forma do que dispõe o artigo 51 do CDC.

Nesta toada, porquanto o contrato firmado entre as partes visa a prestação de serviços à saúde, havendo previsão de cobertura para a doença que a paciente apresenta, é justa a expectativa de cobertura para o tratamento médico que lhe for recomendado.

Enfim, ***"ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão), revela-se abusivo o preceito do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar.*** *Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido, com a imposição de multa. (AgRg no REsp 1450673/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 20/08/2014 (grifei).*

Assim, uma vez que prevê a cobertura para a enfermidade da autora – Lúpus Erimatoso Sistêmico (CID 10: M32.1), não pode o plano de saúde se recusar a autorizar procedimento imprescindível para o tratamento, qual seja, medicação BENLYSTA 400 mg (BELIMUMABE), sob pena de a cobertura da moléstia não ser, efetivamente, realizada.

Anote-se que a escolha do tratamento com o medicamento em liça não se deu por mera opção da autora, mas sim por força do quadro clínico da paciente, consoante se depreende do laudo da reumatologista assistente (id. 107304973):

> "*(…) foram exauridos em seu tratamento médico todos os fármacos constantes do "Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas" da Portaria nº 100/2013 do Ministério da Saúde, pertinentes ao seu quadro clínico, a qual fixa o protocolo de tratamento medicamentoso para o tratamento do Lúpus Erimatoso Sistêmico disponibilizado pelo SUS e não houve resposta clínica satisfatória.*
>
> *(…)*
>
> *Por esse motivo, a paciente necessita de uma medicação adicional ao tratamento padrão já realizado sem sucesso. Os objetivos desse medicamento são: diminuir a atividade da doença e evitar danos futuros a órgãos importantes, reduzir agudizações que levam a internações e emergências, reduzir dores e fadiga que permita retomar suas atividades diárias e possibilite redução de corticoide oral que traz prejuízo à saúde e causam outras doenças."*

No que tange **ao fornecimento de medicação para Lúpus, de uso domiciliar,** colhem-se as jurisprudências que seguem:

> AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. T**UTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO BELIMUMABE. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO**. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS. 1. CONSOANTE A REDAÇÃO DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, MOSTRA-SE NECESSÁRIA A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. 2. INCIDE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, SALVO OS ADMINISTRADOS POR ENTIDADES DE AUTOGESTÃO, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 3º, § 2º, BEM COMO PELO QUE DISPÕE A SÚMULA Nº 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O ARTIGO 35 DA LEI Nº 9.656/1998.3. AO MENOS EM ANÁLISE SUMÁRIA, **TEM-SE COMO DEVIDA A COBERTURA POSTULADA DO MEDICAMENTO BELIMUMABE, SOBRETUDO PORQUANTO CONCERNENTE A TRATAMENTO RECOMENDADO PELO MÉDICO ASSISTENTE PARA PATOLOGIA INCONTROVERSAMENTE COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE**, O QUE IMPLICA O RECONHECIMENTO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO.4. CUMPRE CONSIGNAR QUE O PERIGO DE DANO ADVÉM DO RISCO DE EVOLUÇÃO DO QUADRO CAUSADO PELA ENFERMIDADE QUE, CONSOANTE INCONTROVERSO, ACOMETE A PARTE AUTORA.5. DESSE MODO, RESTARAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.6. TENDO EM CONTA O JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

COM O SEU PARCIAL PROVIMENTO, RESTA PREJUDICADO AGRAVO INTERNO, EM QUE SE DISCUTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (T**J-RS** - AI: 51203479820228217000 BENTO GONÇALVES, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quinta Câmara Cível, **Data de Publicação: 27/10/2022**)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. **PLANO DE SAÚDE. LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO**. OSTEOPOROSE. PARAPLEGIA E FRATURA ESPONTÂNEA. **LAUDO MÉDICO INDICANDO A NECESSIDADE DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PROLIA. EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA PARA MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUE NÃO AFASTA OBRIGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DE FORNECER O MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DA ENFERMIDADE**. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 338 E 340 TJRJ. ROL DA ANS QUE NÃO É TAXATIVO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. **Laudo médico que comprova ser a autora portadora de lúpus eritematoso sistêmico,** com comprometimento neurológico severo e episódios de mielite transversa que evoluiu para paraplegia, estando restrita a cadeira de rodas. Apresenta também fratura espontânea de bacia decorrente de osteoporose. **Necessidade de fornecimento do medicamento PROLIA 60 mg. Escolha do tratamento que não se deu por mera opção da paciente, mas sim por força do quadro clínico, sendo imprescindível para evitar o agravamento da doença, com risco de novas fraturas.** Ausência de previsão do tratamento no rol de procedimentos da ANS que não pode servir de escusa. Além disso, o aludido rol não é taxativo. REsp 1.733.013/PR que não reproduz entendimento pacífico do STJ, sendo que a decisão nele contida não possui efeito vinculante. Em que pese incontestável a validade da cláusula contratual restritiva de cobertura**, a operadora de saúde não pode limitar os procedimentos, técnicas e materiais a serem utilizados pelo médico no tratamento de saúde, sendo vedado o comportamento abusivo, resguardando-se a finalidade básica do contrato, que é a saúde e a própria vida do segurado.** Súmula nº 340 TJRJ. **Cláusulas limitativas ou obstativas das obrigações assumidas que devem ser interpretadas à luz da boa-fé objetiva, e sempre da maneira mais favorável ao consumidor, em consonância com o artigo 47, da Lei 8.078/80, sendo abusiva, e nula de pleno direito, qualquer cláusula que limite a assistência e tratamento do beneficiário**. **Exclusão contratual de cobertura de fornecimento de medicação domiciliar que, por si só, não exime a operadora de planos de saúde de fornecer o medicamento para tratamento, evitando risco de agravamento da moléstia.** Súmula nº 338 TJRJ. Dano material não configurado. Aquisição do medicamento não comprovada. No que tange à indenização por dano moral, a ausência de violação a direitos de personalidade afasta a pretensão de reparação extrapatrimonial. Recusa da ré que não se afigura ilícita, tendo em vista o procedimento não estar previsto no rol da ANS. Em verdade, trata-se de divergência contratual plausível e que se justifica pelo propósito de manutenção do equilíbrio atuarial do plano. Desprovimento dos recursos. (**TJ-RJ** – APL: 00458792720208190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 16/03/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, **Data de Publicação: 18/03/2022**)

Nesse contexto, tem-se a hipótese dos autos preenchendo o critério previsto no inciso I, do parágrafo 13, do art.10, da Lei 9.65/98, tornando-se, portanto, como devida a autorização da medicação, ainda que para ser aplicada em ambiente domiciliar, revelando-se injusta a negativa de cobertura perpetrada pela operadora de plano de saúde ré, prosperando o pleito alusivo à obrigação de fazer.

Quanto ao pedido de indenização por **danos morais**, este também é procedente. Deflui dos autos que a médica que assiste à autora em outra oportunidade anterior (id. 107162631) solicitou o tratamento medicamentoso junto a ré, tendo a operadora de plano de saúde negado a cobertura com suporte em cláusula contratual restritiva, que não se afigura suficiente para produzir efeitos, até porque não está escrita em destaque e que tenha sido dado prévio conhecimento ao usuário.

Há de se pontuar que a parte autora estava em situação de fragilidade emocional e física, posto que estava acometida de doença grave, necessitando submeter-se ao procedimento medicamentoso.

Suportando o autor não só o sofrimento físico, mas, também, a angústia de moléstia grave, cujo tratamento a ré negou-se a custear, resta claro que seu abalo psicológico com a não autorização não se limitou a mero aborrecimento. Insofismável, no caso sob apreço, o dano moral que sofreu a demandante.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a violação a direitos da personalidade, a exemplo dos direitos à saúde e à vida, caracteriza, por si só, o dano moral, não sendo necessária sequer a ocorrência de reação psíquica da vítima, como os sentimentos de dor, vexame, sofrimento etc.

Assim, o dano moral resta configurado, por ter a empresa demandada agido em desrespeito aos mais preciosos bens de um indivíduo, que são sua vida, saúde e dignidade. O entendimento é esposado pelo STJ, a exemplo do seguinte julgado:

> AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL TIRADO DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO CPC. PLANO DE SAÚDE. **RECUSA DE COBERTURA DE MATERIAL ESSENCIAL À REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DE URGÊNCIA (IMPLANTAÇÃO DE MARCAPASSO). DANO MORAL CONFIGURADO**. 1. **A recusa indevida/injustificada do plano de saúde em proceder à cobertura financeira de material essencial ao êxito de procedimento cirúrgico coberto enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já combalido pela própria doença**. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1614203 RJ 2016/0186519-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2017),Suficientemente demonstrado o dano de índole moral, resta fixar o valor da indenização devida, o que faço levando em consideração a gravidade do fato em si, a extensão do dano sofrido, o desgaste emocional suportado pela autora, nos termos do art. 944, do Código Civil, razão por que arbitro a indenização em **R $3.000,00 (três mil reais).**

Quanto aos danos materiais informados, esse não se credencia ao sucesso, tendo em vista que a parte autora não se desincumbiu de provar nos autos a existência de qualquer despesa com a aquisição do fármaco objeto da demanda.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta:

(1) **JULGO PROCEDENTE** o pedido de obrigação de fazer, ao tempo em que, **em sede de cognição exauriente, defiro a tutela antecipada** para condenar a ré a autorizar, custear e garantir a medicação BENLYSTA 400mg (BELIMUMABE), em sua apresentação endovenosa, nos moldes prescritos pela médica assistente (ids. 107304973 e 107304974).

Estabeleço o **prazo de 20 (vinte) dias para cumprimento, a contar da ciência desta sentença**, sob pena de incorrer em multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), restando limitada ao valor anual da medicação a ser fornecida.

Intime-se a ré pessoalmente, em conformidade com a súmula 410 do STJ, para cumprimento da tutela antecipada ora concedida.

Cópia da presente sentença, autenticada por servidor em exercício na Diretoria Cível do 1º Grau, servirá como mandado.

(2) **JULGO PROCEDENTE** o pedido de indenização por danos morais, para condenar a demandada ao pagamento do valor de **R$ 3.000,00 (três mil reais),** corrigidos monetariamente pela tabela ENCOGE a contar do arbitramento e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, tudo até o efetivo pagamento.

Extingo o processo com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (danos morais e custos do medicamento- obrigação de fazer, com valor aferível, nos moldes da Súmula 199 do TJPE, referente ao fornecimento do medicamento pelo período de um ano), na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, proceda a Diretoria Cível à emissão das guias de custas devidas pela parte demandada, com sua posterior intimação para recolhimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência de multa de 20%, sobre o valor devido atualizado, em conformidade com o art. 22 da Lei Estadual nº 17.116/2020.

Transcorrido o prazo sem o pagamento:

i) expeça-se ofício à Procuradoria-Geral do Estado, exclusivamente por meio eletrônico, sat@pge.pe.gov.br (mailto:sat@pge.pe.gov.br), se o débito for igual ou superior a R$4.000,00 (quatro mil reais), caso em que o expediente também deverá ser acompanhado de cópia do título executivo judicial (sentença exequenda e, se houver, acordão), instrumentos procuratórios, atos constitutivos e outros documentos relevantes para o cumprimento de sentença, nos termos do art. 2º, VII, da Instrução Normativa nº 13, de 25 de maio de 2016, do TJPE (art. 3º, I, do Provimento 03/2022, de 10-03-2022, do Conselho da Magistratura;

(ii) expeça-se ofício ao Comitê Gestor de Arrecadação, por meio eletrônico, se o débito for inferior a R$4.000,00 (quatro mil reais) (art. 3º, II, do Provimento 03/2022- CM).

Atente a Secretaria desta Vara ao disposto no art. 3º, § 1º e art. 4º, do Provimento 03/2022 do CM .

Após o trânsito em julgado, se nada for requerido, proceda-se ao arquivamento dos autos.

P.R.I

Recife, 23 de janeiro de 2023.

Virgínia Gondim Dantas

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: VIRGINIA GONDIM DANTAS
23/01/2023 17:56:32
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 122561548

23012317563216600000119778535

IMPRIMIR GERAR PDF